

- **Expediente N.º: EXP202403468**

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE DERECHOS

Vista la reclamación registrada en fecha 12 de febrero de 2024 ante esta Agencia y realizadas las actuaciones procedimentales previstas en el Título VIII de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD), se han constatado los siguientes

HECHOS

PRIMERO: **A.A.A.** (en adelante, la parte reclamante) ejerció el derecho de Acceso frente a XFERA MÓVILES, S.A. (en adelante, la parte reclamada) sin que su solicitud haya recibido la contestación legalmente establecida.

Se reclama por la no atención por la parte reclamada, de la solicitud realizada por la parte reclamante ejercitando su derecho de acceso a grabaciones de llamadas que ha habido entre ambas partes.

La parte reclamante afirma que solicitó a la parte reclamada la transcripción de sus llamadas con ellos. La compañía le responde que no lo ha solicitado en la forma debida.

La parte reclamante indica haberlo hecho como la parte reclamada precisaba: "Conforme a lo previsto por la Agencia Española de Protección de Datos, se ha de considerar que la voz es una característica peculiar e individual de cada persona que la hace identificable, por lo tanto, es un dato de carácter personal.

En consecuencia, el derecho de acceso a la grabación de su voz solicitado por la parte reclamante sí está amparado por la normativa vigente en materia de protección de datos, facilitando la copia de la grabación solicitada a la parte reclamante o, en su defecto, transcripción de su contenido, solicitando en privacida.yoigo@masmovil.com".

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada, para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos.

TERCERO: El resultado del trámite de traslado indicado en el Hecho anterior no permitió entender satisfechas las pretensiones de la parte reclamante. En consecuencia, con fecha 12 de mayo de 2024, a los efectos previstos en el artículo 64.1 de la LOPDGDD, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó admitir a trámite la reclamación presentada.

El mencionado acuerdo concedió a la parte reclamada trámite de audiencia, para que en el plazo de diez días hábiles presentase las alegaciones que estimara convenientes, formulando, en síntesis, las siguientes alegaciones:

*“...Si bien, debe contextualizarse a este respecto, que la contratación de **A.A.A.** se realizó mediante un comercial de fuerza de venta a puerta fría, o también denominados como “Door to Door”, los cuales se caracterizan por realizar únicamente contrataciones de forma presencial.*

*En esta tipología de contrataciones, las únicas grabaciones disponibles por parte de mi representada son las llamadas de verificaciones de las contrataciones que se realizan con nuestro servicio de atención al cliente. Si han existido comunicaciones telefónicas de la interesada **A.A.A.** con el comercial, mi representada lo desconoce, y en ningún caso, se realizan grabaciones en las contrataciones que se realizan en modalidad presencial.*

Así, en relación con su solicitud, la llamada disponible y que ha sido aportada a la interesada con fecha 19 de julio de 2024, es la llamada efectuada con el siguiente detalle:

- *Llamada del 1 de septiembre de 2023 sobre verificación de la contratación.*

No es posible aportar el resto de las llamadas que relaciona la interesada en su solicitud por falta de objeto, al no disponer de la información solicitada.

*Igualmente, **A.A.A.** ha sido informada de esta circunstancia con fecha 19 de julio de 2024 por correo electrónico enviado desde dpo@masmovil.com. A estos efectos, se adjunta el Documento Número 1, como justificante de dicho extremo.”*

CUARTO: Examinado el escrito presentado por la parte reclamada, se traslada a la parte reclamante, para que, en el plazo de diez días hábiles formule las alegaciones que considere oportunas, formulando, en síntesis, las siguientes alegaciones:

1. *“La contratación con YOGIO fue a través de una llamada comercial pero **B.B.B.**, la gestora, me dijo que cuando me llamaran yo tenía que decir que la contratación había sido presencial. Además, en el historial de la conversación de WhatsApp que adjunté ya se lee como yo le digo a **C.C.C.** que he dicho lo que ella me indicó y también se hace alusión a la factura de fidelización.*
2. *¿Si no hubiera ninguna llamada, como puedo darles yo el detalle de la hora y el minuto exacto de cuando se produjeron las llamadas? Esto demuestra que YOIGO, miente.*
3. *En la respuesta de MASMOVIL indican que en la llamada de comprobación de la contratación dicen algo de tarifas de penalización, pero no es lo mismo que la fidelización según me dijo **C.C.C.**.*

4. *Por favor, ruego me manden las llamadas que les he pedido. Tengo derecho a ellas."*

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Competencia

De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1 y 64.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para iniciar y resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: *"Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos."*

II

Cuestiones previas

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 del RGPD, la Agencia Española de Protección de Datos es competente para desempeñar las funciones que se le asignan en su artículo 57, entre ellas, la de hacer aplicar el Reglamento y promover la sensibilización de los responsables y los encargados del tratamiento acerca de las obligaciones que les incumben, así como tratar las reclamaciones presentadas por un interesado e investigar, en la medida oportuna, el motivo de las mismas.

Correlativamente, el artículo 31 del RGPD establece la obligación de los responsables y encargados del tratamiento de cooperar con la autoridad de control que lo solicite en el desempeño de sus funciones. Para el caso de que éstos hayan designado un delegado de protección de datos, el artículo 39 del RGPD atribuye a éste la función de cooperar con dicha autoridad.

De conformidad con esta normativa, siguiendo el trámite previsto en el artículo 65.4 de la LOPDGDD, con carácter previo a la admisión a trámite de la reclamación de ejercicio de los derechos regulados en los artículos 15 a 22 del RGPD, que da lugar al presente procedimiento, se dio traslado de la misma a la parte reclamada para que procediese a su análisis, diera respuesta a esta Agencia en el plazo de un mes y acreditara haber facilitado al reclamante la respuesta debida.

El resultado de dicho traslado no permitió entender satisfechas las pretensiones de la parte reclamante. En consecuencia, con fecha 12 de mayo de 2024, a los efectos previstos en su artículo 64.1 y 65 de la LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada. Dicha admisión a trámite determina la apertura del presente

procedimiento de falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del RGPD, regulado en el artículo 64.1 de la LOPDGDD, según el cual:

“Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se iniciará por acuerdo de admisión a trámite, que se adoptará conforme a lo establecido en el artículo 65 de esta ley orgánica.

En este caso el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación”.

El artículo 58.2 del RGPD confiere a la Agencia Española de Protección de Datos una serie de poderes correctivos a los efectos de corregir cualquier infracción del RGPD, de entre los que se incluye “ordenar al responsable o encargado del tratamiento que atiendan las solicitudes de ejercicio de los derechos del interesado en virtud del presente Reglamento.

III

Derechos de las personas en materia de protección de datos personales

Los derechos de las personas en materia de protección de datos personales están regulados en los artículos 15 a 22 del RGPD y 13 a 18 de la LOPDGDD. Se contemplan los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad.

Los aspectos formales relativos al ejercicio de esos derechos se establecen en los artículos 12 del RGPD y 12 de la LOPDGDD.

Se tiene en cuenta, además, lo expresado en los Considerandos 59 y siguientes del RGPD.

De conformidad con lo dispuesto en estas normas, el responsable del tratamiento debe arbitrar fórmulas y mecanismos para facilitar al interesado el ejercicio de sus derechos, que serán gratuitas (sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del RGPD), y viene obligado a responder las solicitudes formuladas a más tardar en un mes, salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado, y a expresar sus motivos en caso de que no fuera a atender dicha solicitud. Recae sobre el responsable la prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulada por el afectado.

La comunicación que se dirija al interesado con ocasión de su solicitud deberá expresarse en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo.

IV

Derecho de acceso

Conforme a lo establecido en el artículo 15 del RGPD y artículo 13 de la LOPDGDD, *"el interesado tiene derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales"*.

Tratándose del derecho de acceso a los datos personales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LOPDGDD, cuando el ejercicio del derecho se refiera a una gran cantidad de datos, el responsable podrá solicitar al afectado que especifique los *"datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud"*. El derecho se entenderá otorgado si el responsable facilita un acceso remoto a los datos, teniéndose por atendida la solicitud (si bien el interesado podrá solicitar la información referida a los extremos previstos en el artículo 15 del RGPD).

El ejercicio de este derecho se podrá considerar repetitivo si se ejerce en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.

Por otra parte, la solicitud será considerada excesiva cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, que deberá ser asumido por el afectado.

Al igual que el resto de los derechos del interesado, el derecho de acceso es un derecho personalísimo. Permite al ciudadano obtener información sobre el tratamiento que se está haciendo de sus datos, la posibilidad de obtener una copia de los datos personales que le conciernen y que estén siendo objeto de tratamiento, así como información, en particular, sobre los fines del tratamiento, las categorías de datos personales de que se trate, los destinatarios o categorías de destinatarios a los que podrán comunicarse los datos, el plazo previsto o criterios de conservación, la posibilidad de ejercitar otros derechos, el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control, la información disponible sobre el origen de los datos (si estos no se han obtenido directamente de titular), la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, e información sobre transferencias de datos personales a un tercer país o a una organización internacional. La posibilidad de obtener copia de los datos personales objeto de tratamiento no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

V

Conclusión

Comenzaremos diciendo que esta reclamación solo tendrá en cuenta si el derecho solicitado, derecho de acceso, ha sido atendido o no. El resto de las cuestiones planteadas por la parte reclamante sobre las discrepancias con la parte reclamada por la forma de contratación de la línea ya sea telefónico o "door to door", no serán tenidos en cuenta en esta resolución.

En el supuesto aquí analizado, la parte reclamante ejerció su derecho de Acceso, remitiendo a la parte reclamada las fechas, horas y duración de las llamadas exactas, la parte reclamada remitió a la parte reclamante con fecha 19 de julio de 2024 únicamente la llamada del 1 de septiembre de 2023 sobre la verificación de la

contratación, manifestando que no dispone de más información sobre el resto de las llamadas.

Las normas antes citadas no permiten que pueda obviarse la solicitud como si no se hubiera planteado, dejándola sin la respuesta que obligatoriamente deberán emitir los responsables, aún en el supuesto de que no existan datos del interesado en los ficheros de la entidad o incluso en aquellos supuestos en los que no reuniera los requisitos previstos, en cuyo caso el destinatario de dicha solicitud viene igualmente obligado a requerir la subsanación de las deficiencias observadas o, en su caso, denegar la solicitud motivadamente indicando las causas por las que no procede considerar el derecho de que se trate.

Por tanto, la solicitud que se formule obliga al responsable a dar respuesta expresa, en todo caso, empleando para ello cualquier medio que justifique la recepción de la contestación.

En este caso, sin embargo, consta que durante la tramitación de la reclamación que da lugar al presente procedimiento, formulada precisamente por esa falta de respuesta adecuada a la solicitud de ejercicio de derechos, la parte reclamada ha aportado documentación acreditando la comunicación remitida al interesado atendiendo el derecho o informando sobre la decisión adoptada a propósito de la solicitud. Esta respuesta, por tanto, se produce una vez rebasado el plazo establecido.

A este respecto, cabe precisar que la respuesta que corresponde realizar no puede manifestarse con ocasión de un mero trámite administrativo. Por consiguiente, considerando que el presente procedimiento tiene como objeto que las garantías y los derechos de los afectados queden debidamente restaurados, conjugando la información obrante en el expediente con la normativa referida en los apartados precedentes, procede estimar por motivos formales la presente reclamación al haberse emitido la respuesta extemporáneamente, sin que se requiera la realización de actuaciones adicionales por parte del responsable del fichero en orden a emitir una nueva certificación sobre la atención del derecho.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos **RESUELVE**:

PRIMERO: ESTIMAR por motivos formales, la reclamación formulada por **A.A.A.**, contra XFERA MÓVILES, S.A. No obstante, no procede la emisión de nueva certificación por parte de la parte reclamada, al haberse emitido la respuesta extemporáneamente, sin que se requiera la realización de actuaciones adicionales por parte del responsable.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a **A.A.A.** y a XFERA MÓVILES, S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la

Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

1381-090823

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos